

1501563-69.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... ostensivo visando combater o tráfico de drogas. Neste sentido, merece destaque recente precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de Drogas - Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais - Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501563-69.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2277941/2021 - 05º D.P. PIRACICABA, 2277941 - 05º D.P. PIRACICABA, 2832/21/922 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE PAIXÃO ROBERTO

Contr. nº 2021/001081

Aos 17 de agosto de 2022, às 15:50 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu FELIPE PAIXÃO ROBERTO. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GM José Roberto Santos Rocha e GM THIAGO TUBARDINI FERREIRA

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GM Thiago) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e

gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) GM Jose Roberto, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). FELIPE PAIXÃO ROBERTO, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 01h19min, na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 188, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, 7,6g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 95 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 126/129). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitativa foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 09/10, fotos a fl. 09 e 22 e laudo pericial a fls. 147/149. Da mesma forma, comprovada a autoria delitativa. De fato, o réu confessou a prática delitativa. Sua confissão foi confirmada pelas demais provas produzidas nos autos. O GCM relatou, na fase informativa (fls. 02), que "estava em patrulhamento pelo bairro Vila Sônia, juntamente com seu parceiro GCM Rocha e, quando trafegavam pela Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, avistaram um indivíduo sentado sobre um colchão, defronte ao numeral 188. Salienta que o indivíduo em questão ao perceber a aproximação da guarnição, colocou a mão fechada em um buraco no colchão, como se quisesse esconder algo. Tendo em vista o fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico de drogas e a atitude suspeita do sujeito, decidiram abordá-lo. Identificaram-no como sendo Felipe Paixão Roberto e ao proceder a revista pessoal, lograram encontrar R\$5,00 e um aparelho de celular da marca Iphone. Dentro do colchão, encontraram mais R\$85,30 em dinheiro trocado e 52 porções de crack. Mais adiante, cerca de dois metros do referido colchão, mais especificamente no interior de um ralo da calçada, localizaram 43 porções de crack, embaladas de forma semelhante a droga encontrada no colchão, qual seja, em papel alumínio. Ao ser questionado sobre o que fora encontrado disse que os entorpecentes e o dinheiro lhe pertenciam, posto que está comercializando para poder sobreviver, já que está desempregado e em situação de "rua". Quanto ao aparelho celular da marca Iphone, o autuado disse que recebeu como pagamento de um usuário de drogas que comprou R\$100,00 em entorpecentes. Por fim, o acusado contou que vende cada unidade de crack pela quantia de R\$5,00". Em juízo confirmou sua versão.

Acrescentou que as drogas estavam embaladas da mesma forma. Assim, a confissão, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu não ostenta antecedentes criminais (certidão a fls. 141). Em razão disso, pode ser aplicada a causa de diminuição do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei Antitóxicos. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). FELIPE PAIXÃO ROBERTO vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada

improcedente. Com efeito, segundo consta, o réu foi preso em flagrante após sofrer abordagem de guardas municipais, que teriam suspeitado de sua conduta, pois ao perceber a aproximação da viatura policial, ele teria escondido algo no colchão sobre o qual estava sentado. Realizadas as buscas, encontraram no colchão as drogas e dinheiro descritos na inicial acusatória. Ou seja, diante do apurado, forçoso convir que há irregularidades, que invalidam todo o caderno probatório produzido em desfavor do réu, sobretudo quanto a natureza da diligência realizada pelos servidores municipais. Ora, como se sabe, a teor do art. 144, § 8º, da CF, não é tarefa da GCM a investigação de infrações penais ou a prática de policiamento ostensivo para coibi-las. E, no presente caso, ficou demonstrado que os servidores municipais atuaram como se fossem integrantes das forças policiais, o que contraria o dispositivo constitucional supracitado. Com efeito, depreende-se dos depoimentos dos guardas municipais que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos (conhecido como “ponto de venda”) quando decidiram abordá-lo em razão de atitudes suspeitas. Neste cenário, não se pode dizer que qualquer do povo poderia agir o que tornaria a prisão legal (art. 301, do CPP), já que a captura foi precedida de atos, cuja atribuição pertence a agentes policiais. Não é tarefa da GCM a prática de policiamento ostensivo e a realização de atos investigativos como busca e revista pessoal. Os agentes municipais não estão autorizados a efetuar patrulhamento ostensivo visando combater o tráfico de drogas. Neste sentido, merece destaque recente precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Tráfico de Drogas – Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais – Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar – Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal – Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil – Prova ilícita – Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa PROVIDO.” (TJSP; & Apelação Criminal 1500260-53.2019.8.26.0546; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021). E nem há como dizer que eles atuaram amparados no que dispõe o artigo 301, do Código de Processo Penal. Afinal, essa hipótese é reservada para os casos em que o flagrante é claro ou visual. E não para as hipóteses em que a situação de flagrante delito é precedida de uma desconfiança e da prática de atos típicos de policiamento ostensivo e investigativo, como a busca pessoal. Dessa forma, ainda que os guardas tenham agido com boa-fé, a questão é que eles não poderiam ir além da atuação autorizada a qualquer do povo, nos termos da legislação processual penal. E, reitere-se, não se vê qualquer cidadão praticando os atos que os guardas civis praticaram no caso sob exame. Além disso, cabe destacar que os guardas não tem competência para a prática de busca pessoal para apuração de possível ilícito penal. Não se trata de ato que não está dentro das atribuições dos guardas municipais, consoante Constituição Federal (art. 144) e Código de Processo Penal (art. 240 e seguintes). Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró assim ensina: “Há divergência sobre quem teria atribuição para realizar tais buscas. Não se discute sobre a possibilidade de a autoridade policial, federal ou civil, e de seus agentes realiza-las, até mesmo porque constitucionalmente lhes incumbe a atividade de polícia judiciária (CR, art. 144, § 1º, IV, e § 4º). Por sua vez, no caso de policiais militares, a matéria é controvertida. A polícia militar, embora tenha por finalidade a prevenção ao cometimento de crimes, também tem o escopo de atividade de imediata repressão aos delitos. Assim, não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e de imediata repressão a crimes que estejam ou acabaram de ser cometidos, o policial militar não possa, desde que respeitados os requisitos legais, realizar uma busca pessoal, havendo fundada suspeita de que alguém porta uma arma ou certa quantidade de droga. Por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes”. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). Assim, não há a menor dúvida de que a conduta dos guardas,

na hipótese, acabou violando o art. 144, do CF, bem como o artigo 244, do CPP, o que invalida toda a prova que foi produzida a seguir. Afinal, é evidente o nexo existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, por pura falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela absolvição do acusado em decorrência da fragilidade probatória. Isso porque a prova que o incrimina se resume aos depoimentos dos guardas municipais que o prenderam em flagrante. E nessa condição, evidentemente que seus testemunhos não podem ser considerados como totalmente isentos, pois há uma necessidade de justificarem seus atos, mormente porque o policiamento ostensivo a repressão de crimes não são atribuições da Guarda Municipal. Não se quer dizer que eles mentiram e que incriminaram o réu injustamente. Mas apenas que seus depoimentos não possuem a isenção necessária para, por si só, sustentarem uma condenação. Além disso, existindo apenas a prova oral, não se pode dar preferência ao depoimento dos servidores municipais em detrimento do interrogatório do acusado, o qual tem em seu favor a presunção de inocência. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação da pessoa acusada, a Defensoria Pública pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, posto que não houve apreensão de quantidade expressiva de substância. Em favor do acusado também há a atenuante da confissão. Estão ainda presentes os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o acusado é primário e não há sequer indícios de que se dedica a atividades ilícitas ou de que esteja inserido em organização criminosa. Na verdade, pelo que se apurou, tratava-se de mero morador de rua, que passava por dificuldades financeiras. Assim, sua pena deve ser reduzida na fração máxima, o que possibilita, por consequência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo 44, do Código Penal. Caso não reconhecida a minorante, pugna-se para que, ao menos, seja estabelecido o regime semiaberto. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja permitido ao acusado que apresente eventual recurso em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

FELIPE PAIXÃO ROBERTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 01,19 horas, na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes nº 188, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e Comarca, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, 7,6g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 95 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais realizavam diligências no sobredito local e avistaram o réu sobre um colchão. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou esconder algo no referido colchão. Em razão disso, abordaram-no e localizaram em sua posse a quantia de R\$5,00, bem como localizaram no interior de tal colchão mais R\$85,30, provenientes do narcotráfico, e 52 invólucros de crack. Na sequência, realizaram buscas na proximidade e encontraram mais 43 invólucros de crack, idênticos àqueles encontrados.

Conclui a denúncia que todas as drogas pertenciam ao acusado e se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 151). Defesa preliminar apresentada às fls. 154/155. Após, a denúncia foi recebida (fls. 157) e o réu foi citado (fls. 164).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério

Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, arguindo ilicitude da ação dos guardas. No mérito, alegou insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilicitude na ação dos guardas civis e, consequentemente, nulidade da prova.

Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios

para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilegalidade.

Ainda que a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação suspeita e típica da prática de crime do narcotráfico, qual seja, estava postado em conhecido ponto em tráfico de drogas e tentou esconder algo no colchão sobre o qual estava quando notou a aproximação dos guardas civis.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais.

Neste sentido, jurisprudências:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Preliminar - Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico - Possibilidade para averiguação - Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala dos agentes firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime que não comportam alteração - Preliminar rejeitada e recurso desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO j. 05/10/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada a "apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a

pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 25/08/2020) - g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 06/08;
 - 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e fotografia de fls. 22;
 - 3) Laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 147/149, com resultado positivo para cocaína em relação à substância apreendida.
- A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu confessou o crime. Disse que estava vendendo as drogas para se manter e pagar pensão dos filhos. Alegou estar arrependido, sustentando que nunca foi preso ou processado e que, desde os 18 anos sofria, em razão do vício do alcoolismo.

Interrogado em juízo (gravação), repetiu a confissão e a versão anterior, declarando, mais uma vez, arrependido.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o guarda municipal Thiago Tubardini Ferreira declarou que estava em patrulhamento pelo

bairro Vila Sônia, juntamente com seu parceiro GCM Rocha, e, quando trafegavam pela Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, na frente no numeral 188, avistaram o réu sentado sobre um colchão. Viram que, ao perceber a aproximação da guarnição, ele colocou a mão fechada em um buraco no colchão, como se quisesse esconder algo. A atitude suspeita do réu, aliada ao fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas, levou à abordagem. Em revista pessoal, encontraram com ele R\$ 5,00. Dentro do colchão, encontraram R\$ 85,30 em dinheiro trocado e 52 porções de crack. Nas proximidades, cerca de dois metros do colchão, mais especificamente no interior de um ralo da calçada, localizaram 43 porções de crack, embaladas de forma semelhante à droga encontrada no colchão, em papel alumínio. Questionado, o réu afirmou que os entorpecentes e o dinheiro lhes pertenciam e que estava comercializando para poder sobreviver, já que estava desempregado e em situação de "rua", que o aparelho celular recebeu como pagamento de um usuário de drogas e que comprou R\$100,00 em entorpecentes, disse ainda, que vendia cada unidade de crack pela quantia de R\$ 5,00.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) pelo guarda municipal Jose Roberto Santos Rocha.

Anoto que os relatos dos guardas municipais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que nada tinha contra eles.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a

credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e guardava para fins de tráfico 7,6g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 95 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, o réu foi surpreendido pelos guardas municipais parado, em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e esboçou reação típica de quem está cometendo crime ao avistá-los, tentando esconder as drogas que portava no buraco de um colchão sobre o qual estava. Abordado, com ele, foi encontrado dinheiro e, no colchão, diversas porções de “crack” e mais dinheiro trocado.

Nas proximidades ainda havia mais porções da mesma droga, embaladas de forma idêntica às que ele escondeu no colchão.

O próprio réu, nesta audiência, confessou a posse de todas as drogas e seu destino mercantil.

Inconteste, dessa forma, que todas as drogas apreendidas lhe pertenciam e eram destinadas ao comércio, destino este que se reforça com a existência de expressiva quantidade de entorpecentes, incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem fracionadas e acondicionadas em pequenas porções, como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 22).

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. fls. 26/29).

A quantidade de drogas, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que lhe aplico as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão da autoria do crime, mas deixo de diminuir as penas, uma vez que já fixadas no mínimo legal e circunstâncias atenuantes não autorizam a redução além desse patamar.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, o entendimento que vinha sendo adotado por esta magistrada era de que o único compatível com o grave crime em questão, que

traz nefastas consequências para a sociedade, era o fechado.

No entanto, a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de “envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), hipótese dos autos.

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu FELIPE PAIXÃO ROBERTO a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida é decorrente do tráfico (o próprio réu admitiu tal fato nesta audiência), com fundamento no artigo 63, “caput” da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.